

1500749-23.2020.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... inicial que "os denunciados realizam o tráfico de drogas nesta cidade, sendo tal fato de conhecimento da Polícia Militar e da Polícia Civil.

No dia dos fatos, eles tinham guardados os entorpecentes acima descritos no interior da residência onde moravam, sendo que a droga era destinada ao tráfico. Ocorre que, em 22 de dezembro de 2020, policiais se dirigiram até o endereço ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500749-23.2020.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500749-23.2020.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO BARCELOS DUARTE e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. BRUNO BARCELOS DUARTE e AMANDA PORTUGAL respectivamente qualificados nos autos a fls. 36 e 22, foram denunciados e viram-se processados como incurso no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, porque no dia 22 de dezembro de 2020, por volta de 6h30min, na Rua 48-A nº 39, Bairro João Vacaro, nesta cidade e

Comarca, previamente conluiados e mediante unidade de propósitos, teriam guardado e em depósito, para fins de tráfico, “08 (oito) porções de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como maconha, pesando cerca de 169,380 gramas (cento e sessenta e nove gramas e trezentos e oitenta miligramas), 86 (oitenta e seis) microtubos contendo Metil Benzoil Ecgonina, substância vulgarmente conhecida como cocaína, com peso líquido de 25,620 gramas (vinte e cinco gramas e seiscentos e vinte miligramas), e 01 (uma) porção de Metil Benzoil Ecgonina, substância vulgarmente conhecida como cocaína, com peso líquido de 15,070 gramas (quinze gramas e setenta miligramas)”, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É da inicial que “os denunciados realizam o tráfico de drogas nesta cidade, sendo tal fato de conhecimento da Polícia Militar e da Polícia Civil. No dia dos fatos, eles tinham guardados os entorpecentes acima descritos no interior da residência onde moravam, sendo que a droga era destinada ao tráfico. Ocorre que, em 22 de dezembro de 2020, policiais se dirigiram até o endereço de BRUNO e AMANDA portando um mandado de busca e apreensão expedido nos autos 1501351-85.2020.8.26.0210.

Na ocasião, os agentes de segurança pública foram recepcionados por AMANDA e, em cumprimento do mandado, localizaram no quarto do casal (AMANDA e BRUNO) as drogas acima descritas, além de dinheiro. Também foram apreendidos celulares na sala da residência.

Quanto ao total de dinheiro apreendido no imóvel, foram localizados R\$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) em notas, além de várias moedas totalizando R\$ 218,65 (duzentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos) – R\$ 140,80 (cento e quarenta reais e oitenta centavos) mais R\$ 77,85 (setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) em moedas.

AMANDA foi presa em flagrante e BRUNO não estava no local por ocasião do cumprimento do mandado, sendo que o denunciado, ao saber da prisão de sua companheira, apresentou-se na delegacia de polícia e também foi preso em flagrante. As circunstâncias do crime, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, o dinheiro apreendido, as informações prévias em poder da polícia (que resultaram na expedição do mandado de busca) e o laudo de fls. 157/158 evidenciam que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao tráfico.

Os fatos ocorreram à distância de 170 metros de uma creche, a saber, a CEI – Centro de Ensino Infantil 'Dona Dirce Barros Lelis', que consiste em estabelecimento de ensino e local de trabalho coletivo – cf. fls. 129/131.”.

A denúncia de fls. 185/188 foi recebida em 26 de abril de 2021 (fls. 194). Os Réus foram citados (fls. 204 e 206) e apresentaram defesas preliminares a fls. 232/245 e fls. 246/251, rejeitadas a fls. 254/256. Durante a instrução foi colhida prova oral e os Réus foram interrogados (fls. 325/352).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação, absolvendo Amanda e requerendo a parcial condenação do Coacusado Bruno pelo crime de tráfico, nos exatos termos da denúncia, afastando-se, contudo, a causa de aumento de pena (fls. 315/317).

A defesa de Bruno, a fls. 318/324, arguiu nulidades no inquisitorial, que ele não haveria confessado o crime, assim como que não haveria indícios de materialidade e autoria, requerendo sua absolvição e, subsidiariamente, caso condenado, a aplicação do benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de regência e, de qualquer modo, aplicação da pena no piso, para cumprimento desde o início no regime aberto.

Ao seu turno, em fls. 353/384, Amanda destacou, em seus memoriais, que é frágil a prova para autorizar a condenação, daí porque pediu sua absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

## II. Fundamento e DECIDO.

Afasto as preliminares arguidas em fls. 318/320.

De proêmio, inexistente nulidade no interrogatório extrajudicial do Corréu Bruno, uma vez que ele assinou o documento físico, conforme declarada prestada pelo escrivão em fls. 06, sendo que tal documento somente é assinado eletronicamente pela autoridade policial, segundo se percebe em seu rodapé. Bom lembrar que o escrivão possui fé-pública e nem mesmo o Réu, em seu interrogatório, sustentou essa versão, a qual, em verdade, saiu pela tangente quando questionado: “eu não lembro se eu assinei...” (fls. 346). Para deixar claro, o processamento utilizado pela delegacia de polícia foi correto, de acordo com o Comunicado CG 2167/2017, verbis: “Os termos de oitivas e interrogatórios da fase policial serão assinados digitalmente pela Autoridade Policial e os termos físicos assinados por todos permanecerão na Delegacia de Polícia podendo ser solicitados a qualquer tempo”.

De outra forma, irregularidade alguma houve no cumprimento do mandado de busca e apreensão, que foi cumprido justamente no endereço declinado na denúncia: Rua 48-A nº 39, tal qual o descrito em fls. 189/193.

A terceira preliminar se liga ao mérito e ali será enfrentada.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecente está estampada no auto de prisão em flagrante de fls. 01/06, no boletim de ocorrência de fls. 07/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, comprovante de depósito (fls. 126), no auto de constatação preliminar de fls. 16/17, pelos laudos de exame químico-toxicológico a fls. 136/138, 139/140 e 141/143, no laudo pericial de fls. 157/178, além da prova oral colhida durante a persecução.

A autoria do tráfico é certa na pessoa do Corréu Bruno, devendo ser afastada, uma vez pendendo dúvida, em relação à Coacusada Amanda.

Bruno, na fase inquisitorial, confessou a prática do crime, dizendo “estar traficando entorpecentes para pagar uma dívida antiga de drogas e já vem fazendo tais condutas ilícitas há aproximadamente 2 meses, sendo que recebia pelo whatsapp pedindo as drogas e entrega em ponto previamente marcado, alegando ainda que não traficava dentro de sua residência, somente as escondia, sendo que sua companheira não tinha ciência que estava traficando e tampouco que escondia drogas debaixo do colchão, somente o que utilizava para uso 'maconha'. Afirma que 'pegava' os entorpecentes de um desconhecido” (cf. fls. 06).

Em Juízo, alterou por completo sua versão inicial, agora dizendo que saiu cedo para trabalhar e depois de alguns minutos foi informado que pessoas cumpriam um mandado de prisão, em sua casa, contra ele, de tal forma que foi direto para a delegacia se entregar, quando tomou conhecimento, pelos policiais, de que sua esposa teria sido presa e que teriam encontrado entorpecente em sua residência. Mesmo não existindo droga em sua casa, foi pressionado para que dissesse que a droga seria de um tal de Tota, negando fazer isso porque nem mesmo conheceria essa pessoa, em momento algum confirmando que era sua ou de quem quer que fosse. Ademais, convive em união estável com Amanda, não havia droga em sua residência, a creche não é próxima do local, trabalha como autônomo, não faz uso de entorpecente e o dinheiro era seu e de sua esposa, porque recebe auxílio, trabalha em funilaria e entrega pizza (fls. 341/347).

A Corré Amanda, na delegacia, alegou não ser traficante, a maconha apreendida era

de uso pessoal de seu companheiro e desconhecia pinos de cocaína encontrados debaixo da cama. ademais, o dinheiro encontrado na cômoda é seu (fls. 05), ao passo que durante o contraditório negou o teor da denúncia em fls. 348/352, alegando que acordou com os policiais em sua casa com um mandado contra seu esposo, permanecendo na frente do imóvel com o delegado, que disse que a levaria para a delegacia e quando Bruno aparecesse a soltaria. Ademais, entregou seu dinheiro e somente na delegacia ficou sabendo de ter sido encontrada droga, dizendo que não fazia uso, relatando ainda que o forro da parte debaixo de seu colchão foi rasgado, desconhece que seu companheiro faça uso de entorpecente, que ela trabalha no mercado e o dinheiro era fruto do trabalho do casal.

O policial civil Edson, a fls. 325/328, afirmou que cumpriu o mandado de prisão em tela, indo até a residência e ali sendo atendido por Amanda, que informou que Bruno não estava. Entraram na casa e em revista localizaram o telefone celular e no quarto drogas e dinheiro, grande parte em moeda, tendo Amanda dito que era para comprar presente para a filha. A droga encontrou uma parte debaixo do colchão, na parte de dentro, com a Ré declarando não saber de sua existência, ao passo que uma parte menor estava na cômoda e ela disse que era para uso do marido. No mesmo sentido o depoimento do policial civil Mauro, em fls. 329/333.

O delegado de polícia, Evandro, a fls. 334/340, destacou que em cumprimento ao mandado de busca encontraram considerável quantidade de entorpecentes, boa parte debaixo da cama do casal, "sendo 86 pinos de cocaína e não me recordo o peso e mais oito porções de maconha junto com o dinheiro, a maior quantidade em moedas, sendo aproximadamente mil e trezentos reais", dizendo que as investigações se iniciaram com apuração de tráfico e associação e um dos pontos era o casal, que tinha no telefone a negociação dele com a revenda de drogas, declarando que foi apreendido um telefone com o casal, que era transacionada a venda de entorpecentes.

Pois bem.

Ao que se tem, os Réus apresentaram versões conflitantes quando se contrapõe aquelas dadas na delegacia e as prestadas em Juízo. Nem se olvide afirmar que o depoimento prestado em sede inquisitorial não pode ser utilizado. De início, nada fora levantado que tivesse o condão de macular aquela declaração quando da prisão em flagrante, já que afastada a preliminar sobre o tema, lembrando que Bruno estava acompanhado por advogado de sua confiança no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante. No mais, a realização de prova oral durante a instrução confirmou o teor da denúncia contra ele, conforme acima motivado.

No sentido do quanto aqui se decide: "a confissão somente pode ser retratada se a vontade do agente ao confessar estiver viciada a ponto de não poder produzir seus efeitos como ato jurídico. Quem confessa emite uma declaração de vontade, geradora de um ato jurídico. Logo, como todo ato jurídico, se prestada por mentalmente íntegro, só pode ser atingida se a vontade, ao momento da declaração, estiver atingida pelo erro, dolo ou coação. O elemento essencial da confissão, como de todo ato jurídico, é uma vontade livre e consciente. Assim, se mentalmente capaz o confitente, a retratação somente aproveitará se demonstrada que gerada sob influência de uma das causas que viciam a vontade. A lei processual fala que é retratável: acrescentamos, numa ousadia: só valerá a retratação se gerada por vício de inteligência (erro ou dolo) ou de vontade (coação)" (Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, Da prova no processo penal, 5ª ed., São Paulo, Ed. Saraiva: 1999, págs. 111/112).

Diz-se isso porque o depoimento de Bruno dado em Juízo não pode ser admitido, uma vez que não encontra eco nos autos, sendo isolado até mesmo pela declaração prestada em solo policial quando de sua prisão, nada havendo nos autos a menos que indicasse que ele tivesse sido coagido pela autoridade policial para prestar depoimento mentiroso e delatar um tal de Tota, lembrando que estava na presença de

seu advogado. Ademais, o depoimento judicial ficou completamente isolado da prova colhida.

Em relação à Corrê Amanda se vê que não há prova segura que permita sua condenação, sendo inviável se basear, para a imposição do édito condenatório, em indícios consistentes simplesmente no fato de que residia na casa, nada mais havendo que a vinculasse aos objetos ilícitos apreendidos.

De fato, o simples fato de ser companheira de narcotraficante, por si só, não autorizaria a presunção de que teria a Corrê aderido a tal conduta, cabendo prova robusta neste sentido, com base no artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu nestes autos. Nesse panorama: "CONCURSO DE PESSOAS - Crime contra a saúde pública - Descaracterização - Tráfico de entorpecente imputado em co-autoria à esposa do traficante - Fundamentação em presunção de convivência e por filha de pessoa que já se envolveu com drogas - Inadmissibilidade - Inexistência de prova precisa da co-participação - Aplicação do princípio 'in dubio pro reo' - Absolvição mantida" (TJSP -RT 621/290).

Sendo assim, os indícios da vinculação de Paloma ao tráfico não se convolveram em prova certa que permitisse sua condenação. Quanto a tais indícios, merece citação: "O Direito Penal não atua com a possibilidade da ocorrência do fato. É necessário ser ele comprovado. Desta maneira, na ausência de prova indubitosa da imputação, deve haver a absolvição.

Lembro Antonio Joaquim de Macedo Soares sobre o tema: 'É como o Juiz, que há de julgar pelo alegado e provado, 'ainda que lhe a consciencia dicte outra coisa, e elle saiba a verdade ser em contrario do que no feito for provado' como é expresso na Ord. Liv 3º, tit 66, pr.'

Sem dúvida, mesmo o convencimento íntimo do Magistrado não justifica a condenação. Somente a prova cabal, indubitosa é que a legitima." (TJSP, Ap. 0001848-52.2015.8.26.0210, 2ª C.D.Crim., Rel. Des. Almeida Sampaio, j. 18.03.2019).

Assim, à míngua de contexto probatório robusto, não havendo a certeza necessária, em que se evidencia a fragilidade das provas produzidas contra a Coacusada Amanda, não há como se imputar a ela a prática de crime grave, equiparado que é ao hediondo, como é o caso do tráfico de entorpecentes. É de rigor, pois, que as dúvidas geradas pela nebulosidade do conjunto probatório sejam resolvidas em favor da Acusada, em reverência ao princípio in dubio pro reo.

Situação antagônica, contudo, é a de Bruno.

A conduta do Acusado indica que no dia, horário e local apontados na denúncia, tinha em depósito considerável entorpecente para fins de traficância. A isso se chega com a prova coligida aos autos, notadamente a considerável quantidade de entorpecente apreendida em sua residência, a forma como estava escondida e acondicionada esta droga, o fato de ser conhecido dos policiais por envolvimento no tráfico, o dinheiro sem comprovação de origem lícita, a declaração por ele prestada de não fazer uso de drogas, assim pela confissão extrajudicial, tudo apontando, destarte, que o Réu utilizava o entorpecente apreendido exclusivamente para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006.

Some-se a isso que o laudo pericial no aparelho de telefonia celular localizado na residência do Réu, em fls. 157/178, dá conta da traficância, convindo lembrar que, não havendo demonstração de que Amanda estivesse envolvida neste crime, e sendo o telefone, segundo alegado pelos Réus - malgrado por eles não comprovado - compartilhado por ambos, logicamente se deve concluir que eram conversas travadas pelo Acusado. Nesse contexto, de nenhuma necessidade era que a autoridade policial tivesse permissão dos Acusados para acesso ao aparelho e seu conteúdo, porque houve ordem judicial que lhe permitia tal conduta, conforme se pode ver do mandado de

fls. 189/193, especialmente fls. 193.

Dessa forma, considerando todo o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória. Oportuno salientar que “Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado” (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

Nem se olvide pelo fato de a Acusação se embasar somente no depoimento prestado por policiais, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, motivo por que não podem ser descartados.

A condição funcional não os torna suspeitos, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, “Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram” (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência dos delitos e passo a aplicar a pena do Corréu Bruno.

Apreciando os parâmetros legais ditados pelo artigo 59 do Código Penal e pelo artigo 42 da Lei de Drogas, é o caso de majorar a pena-base do Acusado, considerando a grande quantidade de droga apreendida para os padrões desta cidade, abundância que evidencia maior perniciosidade da conduta, razão pela qual majoro sua pena-base e a fixo inicialmente em 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no piso, à míngua de comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase da dosimetria, muito embora tivesse confessado o crime na fase inquisitorial, apresentou versão diversa em Juízo, de tal forma que não pode ser beneficiado com a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

O Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a espécie e quantidade de droga apreendida demonstram que se dedica, exclusivamente, à atividade criminosa do comércio clandestino de drogas. Dessa maneira, torno aquela pena definitiva, ante a inexistência de demais causas legais modificadoras.

Importante consignar que caberia à Defesa a prova de que o Acusado faria jus à causa de diminuição mencionada, considerando-se que esta não é automática e somente de aplicação possível quando presentes os requisitos legais, forte no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal. Desta forma, o Réu deveria indicar, através de provas robustas que trabalhava e não se dedicava a atividades criminosas, afastando o quanto foi comprovado pela Acusação, isto é, que estava em ato de traficância.

Sobre o tema, aliás: "Para redução da pena, essencial que o Réu seja 'primário', apresente 'bons antecedentes', comprove que 'não se dedique às atividades criminosas', assim como, 'nem integre organização criminosa'. Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do Réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder. Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução" (TJSP, Ap. 0003548-97.2014.8.26.0210, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 30.07.2019).

O regime de cumprimento de pena adequado, por se tratar de crime equiparado a hediondo, é o inicial fechado. Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência do requisito subjetivo. Ressalto, quanto tal aspecto que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênica, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que o Acusado possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes hediondos e equiparados.

Ressalto, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do Réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido pelo traficante (ainda que seja um "pequeno" traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabiliza a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada ao crime hediondo. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: "Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de

entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações.

Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido, justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012). E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita" (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, com redação dada pela Lei 11.719, de 20.06.2008, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que o Acusado foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com ele localizado quantia em dinheiro sem comprovação de regularidade em seu recebimento, assim como telefone celular que estava ligado ao tráfico, conforme acima mencionado, evidenciando-se serem fruto da venda de drogas ilícitas, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda dos valores apreendidos com o Réu, depositados em Juízo, que deverão ser encaminhados em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º). Ressalto, quanto a isso, que os documentos de fls. 363/384 não fazem prova de que o dinheiro apreendido juntamente com a droga, mormente diante da grande quantidade de moedas, fosse vinculado ao aludido extrato bancário.



III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência:

- a) ABSOLVO a Corré AMANDA PORTUGAL, com qualificação nos autos, da acusação que pesa contra si, por não existir prova de ter concorrido para a infração penal, com fulcro no artigo 386, inciso V, do CPP; e
- b) CONDENO o Corréu BRUNO BARCELOS DUARTE, qualificado nos autos, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em seu piso mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, vedada a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis. No mais, decreto a perda do dinheiro e do telefone celular apreendidos com ele, em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), bem como encaminhe-se o numerário e o telefone apreendidos com o Réu em benefício da União.

O Corréu Bruno, condenado, aguardou o julgamento em liberdade, motivo por que assim pode permanecer enquanto pendente eventual recurso, deixando, ao menos por ora, de decretar sua prisão cautelar.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Corréu Raphael no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

São devidas custas na forma da lei, pelo Corréu Bruno, que fica isento por ser beneficiário da Justiça Gratuita, pedido de fls. 232 que ora defiro uma vez presentes os requisitos legais.

P.R.I.C.

Guaíra, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA